

0002341-06.2016.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Desobediência

Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: Vara do Juizado Especial Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... favoravelmente à aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Assim, alterou-se o quadro fático, tornando-se potencialmente cabível o instituto negocial. 5. Ordem parcialmente concedida para determinar sejam os autos remetidos à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que aprecie o ato do procurador da República que negou à paciente a oferta de acordo de não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

Vara do Juizado Especial Criminal

Praça José Bonifácio, s/nº, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

0002341-06.2016.8.26.0562 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002341-06.2016.8.26.0562

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Desobediência

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 2/2016 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fernando Jose Ribeiro Casaca

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

FERNANDO JOSÉ RIBEIRO CASACA qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 330 do Código Penal.

Conforme narra a denúncia, o acusado é administrador do estabelecimento Gonzaga Flat, situado no local dos fatos.

Policiais civis, juntamente com funcionários da Sabesp e Prefeitura estiveram no estabelecimento e constataram que os poços artesianos localizados no subsolo, que estavam interditados desde o dia 07 de maio de 2015 pelo poder público municipal, encontravam-se em funcionamento.

Anteriormente, no dia 23 de dezembro de 2015, o estabelecimento também foi autuado pela mesma prática. Ouvido, o acusado confessou ter plena ciência das autuações administrativas, sendo o responsável pela instalação dos poços e administrador do local.

Termo circunstanciado (fls.01/10). Auto de infração (fls.155). Termo de interdição (fls. 156). Relatório informativo da secretaria municipal do meio ambiente (fls. 235).

Tratando-se de autos de competência originária do Juizado Especial Criminal, foi designada audiência preliminar (artigo 70 da Lei nº 9.099/95), na qual o réu não aceitou a proposta de transação penal oferecida pelo Ministério Público (fls. 281). O Ministério Público ofereceu proposta de suspensão condicional do processo (fls.

285), sendo designada audiência (fls. 289).

A denúncia foi recebida em 15/01/2019 (fls. 366).

O acusado foi citado (fls. 314) e apresentou resposta à acusação (fls. 315/319).

Durante a audiência de proposta de suspensão, o réu recusou a proposta de suspensão condicional do processo (fls. 342).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, bem como realizado o interrogatório do réu.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação. Aduziu que durante a vistoria realizada em maio de 2015, foi lavrado termo de interdição, a fim de cessar o uso do poço artesiano no local dos fatos. Desta forma, o estabelecimento não poderia, após a infração de maio de 2015, continuar fazendo o uso do poço artesiano. No entanto, durante vistoria realizada no dia 11/02/2016, em conjunto pela SABESP e Prefeitura, foi constatado que o poço cartesiano continuava em funcionamento. Alegou que o acusado, embora tenha afirmado que desconhecesse os fatos, em especial sobre o impedimento do uso do poço artesiano, identificou-se como o responsável pela administração do estabelecimento Gonzaga Flat. Assim, em razão da natureza do cargo que ocupa, não há dúvidas de que o acusado tinha ciência das intercorrências constatadas no local, havendo provas contundentes em relação à autoria e materialidade delitivas. Por fim, pugnou pela condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

A D. Defesa, por sua vez, preliminarmente, alegou que houve nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento das oitivas das testemunhas Marlúcia e José Roberta, mencionadas no interrogatório do acusado. Aduziu que também houve nulidade em razão da ausência de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, diante da negativa da recusa de celebração do acordo de não persecução penal da I. Promotora de Justiça. Ainda em preliminar, sustentou que a pretensão punitiva estatal está prescrita, visto que já se passaram mais três anos da data do recebimento da denúncia, ocorrendo a prescrição, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal. No mérito, sustentou que dos documentos de fls. 155/156 constam a assinatura da gerente Sra. Marlúcia Franco de Souza, não podendo se atribuir crime de desobediência ao acusado, por ser pessoa diversa da representante no momento da infração. Desta forma, o acusado não cometeu crime algum, pois não recebeu ordem alguma da Administração Pública Municipal. Desta forma, pugnou pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É o relatório

Fundamento e Decido.

Preliminarmente, afasto o alegado cerceamento de defesa, pois, como bem constou no Termo de Audiência de fls. 502/503, quando do indeferimento da oitiva das testemunhas requeridas pela defesa do réu, tais diligências, quando requeridas pelas partes após a produção de provas ao final da audiência, conforme o artigo 402 do Código de Processo Penal, somente podem ser concedidas sob a justificativa de que sua necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, o que, no caso, não se verificou.

Explica Renato Brasileiro de Lima: (...) “se a necessidade daquela diligência já existia à época do início do processo, tal requerimento já devia ter sido formulado pelo Ministério Público ou pelo querelante quando do oferecimento da peça acusatória; pelo lado da defesa, o momento procedimental correto seria o da apresentação da resposta à acusação, já que o próprio art. 396-A estabelece que, na resposta, o acusado deve alegar tudo o que interesse à sua defesa, assim como especificar as provas pretendidas.” (in Manual de Processo Penal, vol. único, 10ª ed. p.1231, Editora Juspodvim.)

Desta forma, tendo em vista que a necessidade da oitiva das testemunhas apontadas pela D. Defesa não surgiu por ocasião da audiência de instrução e julgamento, o momento procedimental correto para requerer a sua oitiva seria o da apresentação da resposta à acusação.

Neste sentido:

“Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes lesão corporal e ameaça, ambos praticados com emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher. Recurso

da defesa. PRELIMINAR. Alegação de nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento judicial de requerimento defensivo, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, de oitivas de duas testemunhas. Não configuração. Ao magistrado, mercê de sua condução de presidente da relação processual, é cometido o poder de definir quais as provas a serem produzidas na instância penal, tendo como parâmetro a sua relevância ao deslinde da causa. Exatamente por ostentar a condição – numa expressão bem significativa e bastante utilizada pela doutrina – de "dominus processus", cabe-lhe indeferir "as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias" (artigo 400, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal). E, desde que o faça de forma fundamentada, tal circunstância não traduz qualquer cerceamento de defesa. Com efeito, o juiz, por ser o destinatário da prova e estar em contato direto com a causa, detém certa discricionariedade na avaliação da necessidade da prova para a formação de seu convencimento, conquanto que delibere. Decisão judicial fundamentada, que não se mostra desarrazoada. O momento adequado para a defesa arrolar testemunhas, sob pena de preclusão, é quando do oferecimento da resposta à acusação (artigo 396-A, do Código de Processo Penal). Preliminar afastada (...)" (TJ-SP - APR: 00007810520188260515 SP 0000781-05.2018.8.26.0515, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 11/11/2021, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/11/2021)

Portanto, a produção da mencionada prova testemunhal encontra-se preclusa, pois como o acusado já tinha conhecimento que tais testemunhas estavam presentes quando dos fatos, deveria as ter arrolado em sua resposta à acusação, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa.

Em relação à preliminar de ausência de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, diante da recusa da I. Promotora de Justiça de celebrar o acordo de não persecução penal, verifico que esta também não há como ser acolhida. Conforme disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, o oferecimento ou não do acordo de não persecução penal, é prerrogativa institucional do órgão ministerial, que poderá oferecê-lo caso o acusado atenda aos requisitos legais.

Deve-se observar, também, como bem destacado pelo Ministério Público, que o acusado não confessou de maneira formal e circunstanciada a prática delitiva, não atendendo ao segundo requisito constante no caput, do artigo 28-A, do CPP.

Assim, patente o descabimento do oferecimento do acordo pretendido pela defesa, visto que o réu não atende aos requisitos legais, como acima disposto.

Foi indeferido, portanto, o pleito para remessa do feito ao Órgão Superior do Ministério Público, visto que é manifesto o descabimento da proposta de acordo, bem como que por se tratar de norma processual penal, o acordo de não persecução penal é regido pelo princípio tempus regit actum, não retroagindo para alcançar casos iniciados antes de sua vigência, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

"PORTE ILEGAL DE ARMA – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – MOMENTO PROCESSUAL SUPERADO – INSTITUTO INCIDENTE NA FASE PRÉ-PROCESSUAL – FATO, ADEMAIS, OCORRIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.964/2019, COM RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E INÍCIO DA AÇÃO PENAL – IRRETROATIVIDADE DA LEI PROCESSUAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – PRELIMINAR REJEITADA. "O acordo de não persecução penal, embora apresente reflexos na esfera penal, é norma processual e, como tal, observa o princípio tempus regit actum, não retroagindo para alcançar casos em que a persecução penal já se iniciou, com recebimento da denúncia, muito menos naqueles finalizados, com prolação de sentença (...)" TJ-SP - APR: 15001155420188260312 SP 1500115-54.2018.8.26.0312, Relator: Jayme Walmer de Freitas, Data de Julgamento: 24/07/2021, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/07/2021) Grifei.

"Habeas corpus. 2. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal. 3. Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. Interpretação do art. 28-A, § 14, CPP a partir do

sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal. 4. No caso concreto, em alegações finais, o MP posicionou-se favoravelmente à aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Assim, alterou-se o quadro fático, tornando-se potencialmente cabível o instituto negocial. 5. Ordem parcialmente concedida para determinar sejam os autos remetidos à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que aprecie o ato do procurador da República que negou à paciente a oferta de acordo de não persecução penal." (HC 194677, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 12-08-2021 PUBLIC 13-08-2021). Grifei.

No mais, a Defesa não se desincumbiu de comprovar os supostos prejuízos sofridos pelo réu, o que é essencial para que sejam reconhecidas as nulidades arguidas, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal, pois a mera alegação de que houve prejuízo ou presunção que este tenha ocorrido, mas sem a sua demonstração, não é suficiente para o reconhecimento das nulidades suscitadas pela parte.

Neste sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"(...) Esta Suprema Corte, aliás, tem entendimento consagrado no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Isso porque a demonstração de prejuízo, "a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas" (STF - HC: 184381 SP 0090591-21.2020.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/02/2021, Data de Publicação: 26/02/2021) Grifei.

"(...) Inicialmente, importa ressaltar, que se consolidou no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que é necessária a demonstração do prejuízo que os réus tenham sofrido, para que seja reconhecida a nulidade, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, que diz nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial da Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual se a irregularidade não foi suscitada em prazo oportuno e nem vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. (STF - HC: 196435 AC 0112238-72.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/02/2021, Data de Publicação: 09/02/2021) Grifei.

No mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo termo circunstanciado (fls. 01/10), auto de infração (fls.155), termo de interdição (fls. 156), pelo relatório informativo da secretaria municipal do meio ambiente (fls. 235), bem como pela prova oral colhida durante a fase de instrução.

A autoria também é inconteste e atribuída ao acusado.

A testemunha de acusação, MARCO AURÉLIO NEVES DA SILVA, funcionário público municipal, disse que a prefeitura recebeu uma denúncia via SABESP, de que estabelecimento Gonzaga Flat estaria utilizando um poço artesiano. Posteriormente, compareceu ao local junto com a SABESP e a polícia civil, assessorando a Coordenadoria de Vigilância em Saúde II, responsável pela fiscalização da vigilância sanitária e da saúde do trabalhador. Chegando ao local dos fatos, foi constatado que havia um poço artesiano em funcionamento no subsolo, em uma sala na garagem do edifício. Os atos administrativos, foram realizados pela secretaria de saúde e pela secretaria de finanças, visto que o código de posturas não permite a utilização de poços artesanais na cidade, quando o local possui abastecimento da rede de água. Disse que sempre que há uma queda significativa do consumo de água, uma fiscalização é realizada pela SABESP, para verificar se há algum tipo de vazamento. Afirmou que ocorreram duas visitas, uma para constatar os poços artesanais e a outra para verificar se o Gonzaga Flat continuava a utilizá-los, mesmo com a sua interdição. Durante a primeira visita, não foi apresentado o documento de outorga do DAE e a aprovação do projeto. A fiscalização dos poços artesanais é realizada pela prefeitura, através da aprovação do projeto do poço artesiano e pela secretaria do estado, a qual realiza a emissão de outorga

verificando a quantidade e qualidade do fornecimento de água. Na segunda visita, o estabelecimento foi multado pela secretaria de finanças e pela secretaria de saúde, visto que continuou a utilizar os poços artesianos interditados na primeira fiscalização.

A testemunha de acusação, GEORGE MENSYSKI, policial civil, disse que foi acionado pela chefia do GOE, para dar apoio aos engenheiros da SABESP e os funcionários da prefeitura na fiscalização que foi realizada no local dos fatos. Chegando no local, além do posso artesiano, encontrou bombas hidráulicas enchendo as caixas de água, bem como cloro para realizar a sua limpeza.

O réu, FERNANDO JOSÉ RIBEIRO CASACA, interrogado, negou os fatos narrados na denúncia. Disse que na data dos fatos, foi informado pela gerente do estabelecimento, Senhora Marilúcia Souza, que uma nova fiscalização havia sido realizada no Gonzaga Flat. Foi informado pelo engenheiro responsável pela área dos poços, que o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAAE) havia concedido a dispensa da outorga. Durante a fiscalização, foi realizada uma coleta da água para análise, que posteriormente constatou que não havia qualquer alteração qualitativa. Foi orientado pelo engenheiro que não havia qualquer irregularidade no poço artesiano, motivo pelo qual não houve a interrupção do seu uso. Afirmou que em nenhum momento houve a interdição do poço. Durante a primeira fiscalização, não acompanhou o procedimento pois estava ausente. Disse que é administrador da empresa que gerencia a parte da hoteleira do Gonzaga Flat, não possuindo poder para tomar decisões em nome do condomínio. Contou que o síndico do Condomínio determinou a instalação dos poços artesianos e que apenas a acompanhou.

Este é o cerne do conteúdo probante angariado ao feito.

A prova colhida é suficiente para a condenação do acusado, pois foi devidamente comprovado que ele desobedeceu ordem legal emanada por funcionário público, visto que continuou a utilizar os poços artesianos previamente interditados para abastecer a rede de água do estabelecimento Gonzaga Flat.

Desta forma, verifico que há nos autos elementos de convicção suficientes para a condenação do acusado pelo delito descrito no artigo 330, caput, do Código Penal. As testemunhas de acusação, em especial Marco Aurélio, descreveram, com detalhes, o episódio protagonizado pelo acusado, no sentido de que, na data dos fatos, este, apesar de ter ciência de que os poços artesianos haviam sido interditados pela prefeitura, deu continuidade ao seu uso.

Logo, restou demonstrado que o acusado, ciente da interdição dos poços artesianos, conforme termo de interdição de fls. 156, dolosamente desobedeceu ordem legal de funcionário público.

De mais a mais, em que pese o acusado ter negado os fatos a ele imputados em seu interrogatório, afirmando em nenhum momento houve a interdição dos poços artesianos que funcionavam no local dos fatos, não é o que se verifica da análise do termo de interdição de fls. 156.

Nesse passo, verifico que a versão apresentada pelo acusado restou enfraquecida, cabendo ressaltar que a D. Defesa não foi capaz de trazer aos autos qualquer elemento probatório que tivesse o condão de infirmar toda a prova produzida na instrução criminal.

Portanto, comprovadas autoria e materialidade delitivas e, não incidindo na espécie nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, é imperativo condenar o réu pelo crime descrito no artigo 330, caput, do Código Penal.

Passo à aplicação da pena.

Na primeira fase da dosimetria, atento-me às circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima.

Assim sendo, observo que a culpabilidade demonstrada pelo réu excede ao que normalmente ocorre para o tipo penal previsto. Culpabilidade é o grau de reprovabilidade da conduta, de acordo com as condições pessoais do agente e das características do crime.

Nesse sentido, a utilização dos poços artesianos pelo acusado, além de representar o descumprimento de ordem legal de funcionário público, comprometeu a saúde dos

hóspedes e moradores do Gonzaga Flat, que apresentaram coceiras no corpo em razão da má qualidade da água fornecida pelo estabelecimento, que possuía uma coloração escura e por vezes cheirava mal, conforme se depreende dos termos de declaração de fls. 172/173; 176 e 178/179, evidenciando o maior grau de reprovabilidade de sua conduta.

Deve-se ressaltar, também, a motivação do crime, pois a utilização ilegal dos poços, desrespeitando ordem legal de funcionário público, que comprometeram a saúde pública, em especial dos moradores e hóspedes do Gonzaga Flat, teve como motivação o ganho financeiro desmedido, que se sobrepôs a qualquer consequência negativa que poderia advir da conduta do acusado, fato que evidencia a necessidade de aumentar a reprimenda a ser imposta ao réu.

Desta forma, aumento a pena-base em 1/3, fixando-a em 20 (vinte) dias de detenção e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase e terceiras fases, observo que não se encontram presentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo pena, por definitivo, em 20 (vinte) dias de detenção e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

No entanto, em razão da pena ora aplicada, não se pode olvidar que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

No caso concreto, o réu foi denunciado como incurso no artigo 330, caput, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 15/01/2019 (fls. 366), e o prazo prescricional, de três anos, previsto pelo artigo 109, inciso VI, do Código Penal, foi interrompido e passou a correr a partir desta data.

Desta forma, verifico estar ultrapassado o lapso prescricional aplicado à espécie, devendo, assim, ser decretada a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, posto que decorridos mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e o julgamento do presente processo.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu FERNANDO JOSÉ RIBEIRO CASACA, qualificado nos autos, pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no disposto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Santos, 14 de fevereiro de 2022.

Leonardo de Mello Gonçalves

Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA